

1502740-78.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONES SILVA PINTO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

DIONES SILVA PINTO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 22 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502740-78.2020.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502740-78.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONES SILVA PINTO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

DIONES SILVA PINTO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 02:30 horas, na Rua M 8, nº 812, Cherveson, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, 982 (novecentos e oitenta e dois) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 120,77 gramas, 05 (cinco) invólucros plásticos contendo a mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido de 469,33 gramas, e 233 (duzentos e trinta e três) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, totalizando massa líquida aproximada de 531,97 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 24/26 e exame químico toxicológico definitivo as fls. 78/80, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 3 de novembro de 2020. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo a pena ser cumprida em regime prisional inicial fechado, com imposição ainda da pena de perdimento dos valores apreendidos.

Já a ilustre Defensora Pública inicialmente sustentou comprometida a materialidade do delito em função da ilícita busca realizada, porque em violação ao domicílio do acusado, a determinar a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida, no que diz com a posse e a destinação mercantil do entorpecente, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com fixação de regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo a recidiva específica, promovendo-se a restituição dos valores apreendidos e facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Interposto recurso de apelação por parte da i. Defensoria Pública, pelo v. Acórdão de fls. 276/288 rejeitou-se a preliminar suscitada, dando-se parcial provimento ao apelo apenas para que se promovesse a devolução do numerário apreendido ao réu, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

No entanto, em função da impetração de Habeas Corpus o E. Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para: a) declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, bem como as provas dela decorrentes; b) cassar o Acórdão impugnado e a sentença condenatória; e c) determinar ao juízo de origem que desentranhe as provas ora declaradas ilícitas dos autos e promova novo julgamento da ação penal, como entender de direito.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo e ainda guardava e tinha em depósito o entorpecente indicado na denúncia, além de petrechos relacionados ao comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 114/116, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetrahydrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha.

Quando da prolação da sentença condenatória, cuja nulidade foi declarada pelo v.

Acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 344/356), observou-se que a materialidade do delito não estaria comprometida, por derivação, em razão da apreensão realizada no interior da moradia do acusado, entendendo-se não violada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Este também o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a sentença condenatória, conforme se extrai do v. Acórdão de fls. 276/288. Entretanto, por força da impetração de Habeas Corpus, conforme acima anotado, em v. Acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem reclamada, sobre ter declarado a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca e apreensão domiciliar, porquanto ilícita, ressaltou que: "No entanto, observa-se que o acervo probatório presente nos autos não está composto exclusivamente pela prova declarada ilícita e suas derivações, havendo outros elementos probatórios - apreensão prévia de drogas durante a busca pessoal (a respeito da qual não há insurgência defensiva, tampouco manifestação das instâncias ordinárias) e prova testemunhal" (fls. 354).

E, por força dessa ressalva, determinou a este juízo que, desentranhadas as provas declaradas ilícitas, promovesse novo julgamento da ação penal, valendo-se, portanto, das provas remanescente produzidas.

Deste modo, cumpre reiterar que, na ocasião dos fatos, consta que os Policiais Militares, quando em patrulhamento, em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado com uma sacola, o qual empreendeu fuga quando notou a aproximação da viatura policial. Diante destas circunstâncias, após breve acompanhamento, foi o acusado abordado quando buscava ingressar no interior da moradia, com ele sendo apreendida a referida sacola, em cujo interior havia centenas de "ependorfs" contendo cocaína, além de certa quantia em dinheiro e diversas moedas.

Em função da apreensão da substancial quantidade de entorpecente, admitindo o acusado a realização do comércio ilícito, considerou-se fundadas as razões para o ingresso na moradia -- o que se mostrou, em razão do v. Acórdão de fls. 344/356, ilícito --, seguindo-se a apreensão no interior do imóvel de várias porções de cocaína, maconha, além de mais de mil cápsulas plásticas, comumente utilizadas no embalamento da cocaína, plástico filme, balança, copo de liquidificador e folhas com anotações (cf. fls. 111/112), com anotações sugestivas do tráfico de entorpecentes, que estão sendo desentranhadas do processo, porque consideradas em afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No entanto, a autoria atribuída ao acusado, pela prova remanescente, foi evidenciada.

Deixando ao largo o silêncio mantido na fase inquisitória (fls. 10), em juízo o acusado negou a prática do delito que lhe é irrogado, afirmando, em suma, que Policiais Militares o abordaram quando estava dormindo, no interior da moradia, admitindo que mantinha tão somente no local poucas porções de maconha, destinadas ao próprio uso.

Todavia a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências, que culminaram na apreensão do entorpecente -- ainda antes do ingresso na moradia--, afirmaram que quando em patrulhamento, em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado com uma sacola, o qual empreendeu fuga quando notou a aproximação da viatura policial. Diante destas circunstâncias, após breve acompanhamento, foi o acusado abordado quando buscava ingressar no interior da moradia, com ele sendo apreendida a referida sacola, em cujo interior havia centenas de "ependorfs" contendo cocaína, além de certa quantia em dinheiro. Com a apreensão, o acusado admitiu a prática do comércio ilícito, com a observação de que mantinha mais no interior da moradia, seguindo-se diligências que foram consideradas ilícitas.

Como se tem reiteradamente exposto, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que os policiais militares estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado.

Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no

desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorреitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Para além da idoneidade de que gozam os testemunhos dos Policiais, afronta o bom senso estivessem mantendo a substancial quantidade de entorpecente apreendida em poder dele, antes do ingresso na moradia, com o propósito de incriminá-lo indevidamente.

E não se mostra necessária, à configuração do delito, de tipo múltiplo, a verificação do efetivo comércio do entorpecente, bastando que as circunstâncias evidenciem que esteja destinado à comercialização.

No caso, as circunstâncias evidenciam, às escâncaras, a destinação mercantil, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o acusado, quando se encontrava em via pública, após ainda ter empreendido fuga, cuidando-se de centenas de eppendorfs contendo cocaína.

Deste modo, os elementos probatórios remanescentes colhidos possibilitam seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, sendo incontornável um desfecho condenatório.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena-base deve ser agravada, entretanto, em 1/6 (um sexto), em função da recidiva (fls. 28), somando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, não há lugar para a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, dada a apontada recidiva, como também em função da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, já embalada e individualizada, compondo centenas de porções, revelando que não se tratava de um neófito, destinatário do privilégio, mas de alguém que estava dedicado ao tráfico.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado DIONES SILVA PINTO à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a recidiva e a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar

vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena. Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, ainda: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u.,

RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA